

1500169-50.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-50.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-50.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

MICHAEL MARCELO MARTINS PEIXOTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MICHAEL MARCELO MARTINS PEIXOTO e LAYLA GRAZIELE MATIAS INÁCIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 16h, na Avenida América Agreli, 171, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam com eles, para futura entrega a terceiros, vinte e seis porções de cocaína, pesando 28g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portarem R\$ 463,00.

Narra, ainda, a inicial, terem se associado, os réus, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram os réus na via, localizando-se, nas vestes de Michael, dezesseis porções de cocaína, um celular e

R\$ 423,00. Com a ré Layla, os agentes encontraram dez invólucros plásticos contendo o tóxico, um celular e R\$ 40,00.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia. Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual se ouviram duas testemunhas comuns.

Após, foram interrogados os réus

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus alegando, em suma, serem insuficientes as provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Sem razão a defesa ao afirmar ter sido revistada a ré por policial masculino, pois nenhuma prova se produziu neste caminho.

Ainda que assim não fosse, eventual irregularidade, ocorrida quando da fase do inquérito, nenhum efeito produziria após encerrada a regular instrução.

Por isso, não há falar-se em irregularidade da abordagem aos réus nem tão pouco à formalidade do registro da ocorrência.

Assim, AFASTO as preliminares levantadas.

Passo ao mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão acostado aos autos às fls. 15/17, que revela o encontro do entorpecente, do dinheiro e dos celulares em tela.

Ainda, no pertinente à materialidade, há o laudo de constatação de fls. 22/25 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 123/125, concludentes no sentido de se tratar de cocaína, a substância achada.

Os celulares foram vistoriados (fls. 127/134).

Em ambas as manifestações, admitiu o réu Michael a prática do comércio ilícito, contudo negou participação da corré, com quem mantém relacionamento amoroso.

A ré Layla, na fase administrativa, disse que apenas mantinha a posse do entorpecente comercializado pelo namorado Michael.

Em Juízo, contou a ré estar na companhia do réu e namorado, em um bar, quando se apoderou de uma pochete deste. Primeiro, aduziu ter pretendido se desfazer do produto ilegal, existente na pochete. Ao depois, disse ter guardado o tóxico nas vestes.

Toda a contradição e fala fantasiosa, pela ré, revela somente o comércio ilegal, que de forma repetida exercia, em concurso com o corréu, para sustento do casal.

Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordado os réus na via pública, ocasião na qual encontraram, nas vestes de Michael, dezesseis microtubos de cocaína, um celular e R\$ 423,00. Explicaram ter Layla, espontaneamente, apresentado o restante da droga, do dinheiro e um celular, que se achavam na posse dela.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, guarda ou transporte, por parte de ambos.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues). Ainda sobre o assunto: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). Por fim: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com os réus em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos.

Como bem destacaram as partes, foram os réus surpreendidos agindo em concurso de crimes, não se podendo afirmar na existência de associação para a venda do entorpecente.

Neste sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre os agentes, uma vez que a condenação está amparada apenas na presunção de que para traficar drogas no Complexo do Chapadão, localidade sob o comando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", o paciente necessariamente deveria integrar a referida organização e teria uma função pré-determinada, a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, HC 415.974/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/10/2017).

No mais, não há dúvida no sentido de terem dividido os réus as atribuições para que o tóxico fosse comercializado, ou seja, juntos, no bar, obtinham lucro ilícito com a venda do produto que obtinham, partilhavam, transportavam e guardavam com eles. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos os réus posta em comércio, até porque, não contam com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que façam os réus uso do tóxico, mas a venda é certa, até para garantia do uso.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- MICHAEL MARCELO MARTINS PEIXOTO:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 320/325), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria e com a menoridade do acusado, circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, "c", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena.

- LAYLA GRAZIELE MATIAS INACIO:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a menoridade da acusada, circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os réus, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu Michael respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela, ante a quantidade de entorpecentes; a reincidência de Michael; e o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade dos réus, indicando dedicarem-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Neste sentido, o RHC nº 116.926, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13, no qual se decidiu que: "a conduta social do réu, o concurso de agentes,

a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010" (g.n.). O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno MICHAEL MARCELO MARTINS PEIXOTO, R.G. n.º 58.453.763 e LAYLA GRAZIELE MATIAS INACIO, R.G. n.º 49.982.859, cada um, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal.

Não poderá o réu Michael apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu Michael no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

Porque aguardou a ré Layla a instrução do feito em prisão domiciliar, faculto eventual apelação nessa mesma condição, devendo-se observar as medidas cautelares determinadas às fls. 231/232.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do dinheiro e dos celulares (fls. 16/17), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA